

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>
[예상][13.02-2]상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

《【문제13.2】
<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.
乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 더 이상 이 사건으로 다투지 않겠 다며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.
또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미 칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음2) 甲이 상소권 포기 합의 후 제기한 항소가 적법한지 여부를 상소권 포기의 방식 및 효력과 관련하여 논하고, 전부 승소한 丙이 판결 이유만을 다 투기 위해 제기한 항소에 상소의 이익이 인정되는지 판례의 태도인 형식적 불복설에 근거하여 기술하시오.》

<문제13.2의 물음2> 상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 상소권 포기에 관한 합의를 한 후 항소를 제기하였고, 丙은 전부 승소판결을 받은 뒤 판결 이유의 사실인정만을 다투기 위해 항소 하려는 상황이다. 쟁점으로 <상소권 포기의 방식과 효력에 따른 항소의 적법 여부> 및 <전부 승소한 당사자에게 판결 이유에 대한 상소의 이익이 인정되 는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상소권 포기의 요건과 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부를 기술한다.

- 상소는 당사자의 자유로운 의사에 따라 포기할 수 있으나, 그 방식과 시기에 일정한 제한이 있다. 사안에서는 甲이 乙과 상소권 포기 합의를 한 후 항 소를 제기한 경우 그 항소의 적법성 여부가 문제된다. 또한, 전부 승소한 丙이 판결 주문이 아닌 이유 중의 사실인정을 다투기 위해 항소할 수 있는지와 관련하여 상소의 이익에 관한 판례의 태도인 형식적 불복설을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 대하여 살펴본다.

II. 상소권의 포기

1. 의의 및 방식

(1) 의의

- 상소권의 포기란 상소권을 행사하지 않겠다는 당사자의 의사표시이다. 이는 소송계속 중 또는 판결 선고 후에 이루어질 수 있으며, 상소권을 소멸 시키는 효과를 가진다.

(2) 방식 (민사소송법 제394조)

- 상소권의 포기는 상소를 제기하기 전에는 제1심 법원에, 상소를 제기한 후에는 기록이 있는 법원에 서면으로 신청하여야 한다. 다만, 변론기일 등 에서는 말로 할 수 있으며 이를 조서에 기재하여야 한다.

2. 상소권 포기 합의의 효력

(1) 소송외 합의의 성질

- 사안과 같이 당사자 쌍방이 법정 밖에서 만나 ‘더 이상 다투지 않겠다’고 약정하는 것은 이른바 부상소의 합의(소송협약)에 해당한다. 판례는 이러 한 소송외 합의가 유효하기 위해서는 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하고, 특정된 법률관계에 기반하며, 합의 시 당사자가 예상할 수 있는 범위 내여야 한다고 본다.

(2) 위반 시의 효과

- 적법한 부상소 합의가 있음에도 불구하고 상소를 제기한 경우, 판례는 이를 권리보호의 이익이 없는 부적법한 상소로 보아 각하 판결을 내린다.

III. 상소의 이익과 형식적 불복설

1. 상소의 이익의 의의

- 상소의 이익이란 상소를 통해 제1심 판결보다 유리한 판결을 얻을 수 있는 가능성을 의미한다. 상소의 이익이 없는 상소는 부적법하여 각하된다.

2. 판단 기준에 관한 판례의 태도 (형식적 불복설)

(1) 개념

- 판례는 상소의 이익 유무를 판단함에 있어 원칙적으로 형식적 불복설을 취하고 있다. 이는 당사자가 제1심에서 신청한 청구취지와 비교하여 판결 주문상 그보다 적은 결과를 얻었을 때(일부 패소)에만 상소의 이익을 인정하는 견해이다.

(2) 구체적 적용

- 승소 판결의 이유에 불만이 있다 하더라도 주문에서 청구한 바를 전부 얻어냈다면 원칙적으로 상소의 이익이 없다. 즉, 사실인정의 오류나 법리 판 단의 불만은 상소 사유가 되지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 항소 제기 건

(1) 합의의 효력

- 甲은 판결 선고 후 乙과 상소권을 포기하기로 합의하였다. 이는 특정된 손해배상청구 사건에 관한 것으로서 유효한 부상소의 합의이다.

(2) 항소의 적법성

- 甲이 합의를 어기고 항소를 제기한 것은 소송법상 신의칙 또는 부상소 합의의 효력에 반하는 것으로서 권리보호의 이익이 없다. 따라서 甲의 항소 는 부적법하여 각하되어야 한다.

2. 丙의 항소 제기 건

(1) 사실관계의 확인

- 丙은 제1심에서 전부 승소 판결을 받았다. 판결 주문은 丙이 원하는 대로 소유권이전등기를 명하고 있다.

(2) 상소의 이익 판단

- 형식적 불복설에 의하면 전부 승소한 丙은 판결 주문에서 불이익을 입은 바가 없다. 비록 판결 이유 중 매매계약 성립 시점에 대한 판단이 자신의 주장과 다르다 하더라도, 이는 기판력이 발생하는 주문의 결론이 아니므로 상소로써 다툴 이익이 없다. 따라서 丙의 항소 역시 부적법하여 각하 대상이다.

V. 결론

- 甲의 항소는 유효한 상소권 포기 합의에 위반하여 제기된 것이므로 소송법상 권리보호이익이 없어 부적법하다. 또한 丙의 항소는 판결 이유만을 다투기 위한 것으로서, 형식적 불복설을 취하는 판례의 태도에 비추어 볼 때 전부 승소한 자에게는 상소의 이익이 인정되지 않으므로 이 또한 부적법하다. 민사소송 절차는 판결 주문상의 불이익을 구제하는 것을 목적으로 하므로, 당사자 간의 합의나 객관적인 승소 결과는 절차의 종료를 정당화하는 강력한 근거가 된다.